

1502200-37.2020.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/07/2022

... de fachada que, na verdade, era ponto de tráfico de entorpecentes), e os péssimos antecedentes criminais, circunstâncias concretas obstativas da aplicação da referida minorante. 8. Ordem denegada." (STF HC 111.666/MG Rel. Min. Luiz Fux j. 08.05.12 DJU 23.05.12).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

2ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Mauá-SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502200-37.2020.8.26.0540 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502200-37.2020.8.26.0540

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2307144/2020 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 15123704 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO

GARBINO, 4868/20/124 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 2307144 - 01º DP MAUÁ-

DR.ALFREDO GARBINO, 4868/2020 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY CARVALHO OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

WESLEY CARVALHO OLIVEIRA foi denunciado por incursão no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que no dia 09 de dezembro de 2020, por volta das 22 horas, rua

Andirá, 100, Jardim Paranaíba, nesta cidade e comarca de Mauá, o acusado trazia consigo, guardava e expunha à venda, para entrega a consumo de terceiros, drogas ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 16-7 e laudo de constatação de fls. 21-3. Recebida a denúncia, o réu foi citado (fl.135) e apresentou resposta à acusação.

Durante a instrução, a testemunha arrolada pelas partes foi devidamente inquirida. Por fim, interrogou-se o réu.

Em memoriais, pleiteia o Ministério Público a procedência da ação, enquanto a Defesa requer a nulidade da instrução por inobservância ao procedimento relativo ao acordo de não persecução penal. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória ou, ao menos, a aplicação da pena nos patamares mínimos, com o reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação de regime penitenciário inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É a síntese do necessário.  
Fundamento e decido.

Malgrado o esforço argumentativo do douto Defensor Público, a preliminar levantada não se sustenta. A questão atinente ao acordo de não persecução penal já foi devidamente afastada no momento oportuno (fls.141-7).

No mérito, a acusação procede.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 02-4), auto de exibição e apreensão (fls. 16-7), laudo de constatação (fls. 21-3), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 165-7), além da prova oral colhida.

Comprovou-se a autoria.

Interrogado, em solo policial (fl. 07), o réu permaneceu em silêncio. Em juízo, negou o ocorrido. Disse que marcou um encontro com uma menina no local dos fatos e estava comendo. Não correu e não tinha sacola. Os policiais acharam as drogas no beco, ao lado do barraco onde ficaria com a menina (mídia digital).

O policial militar Nei, na fase administrativa (fl.05), historiou que: (sic) "hoje, por volta das 22:00 horas, estávamos em patrulhamento pela rua Andirá, no bairro Paranaíba, local conhecido pela mercancia de drogas, quando na altura do nº 100, vimos um indivíduo sentado na calçada, o qual, ao ver a nossa aproximação, jogou ao seu lado uma sacola que estava em suas mãos, levantando nossa suspeita. O sujeito foi abordado e se identificou como Wesley. Em revista pessoal, nada de ilegal foi localizado na sua roupa, contudo, no interior da sacola que outrora estava com ele, encontramos diversos invólucros preenchidos com o que parecia ser maconha, cocaína e crack. Além das substâncias, havia também 1 (hum) telefone celular e R\$ 100,00 (cem reais). Indagado sobre os objetos, Wesley negou que estivesse com ele e negou tê-los jogado ao seu lado".

No mesmo sentido o depoimento do policial Edgard (fl.06).

Em juízo, o policial Edgard afirmou que o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Na viela, viram o réu comendo uma marmita. Ao notar a presença dos policiais, largou a marmita, jogou a sacola que estava em seu colo de lado e tentou correr. Foi abordado e na sacola foram encontradas as drogas maconha, crack e cocaína, a quantia de R\$100,00 em dinheiro e um aparelho celular. O acusado disse que estava no tráfico de drogas há um tempo porque precisava trabalhar. Disse que

em razão do transcurso do tempo não lembra se o acusado negou os fatos na Delegacia (mídia digital).

A prova por meio de depoimento de policiais não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia diante de uma acepção processual de pessoas com apoio em predicado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa simpliciter de menor credibilidade a circunstância de uma testemunha ser policial. Nessa linha:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07).

Observe-se que o depoimento prestado em juízo pelo policial militar além de plenamente coerente, está em perfeita harmonia àquele por ele prestado perante a autoridade policial. Ademais, não há qualquer motivo a que não possa ser atribuído total crédito a tal depoimento. Não há nos autos prova alguma, sequer indícios, de que tivesse motivo particular, injusto, para incriminar falsamente o réu.

Ressalta-se que pequenas divergências, acerca de elementos periféricos da abordagem, não são aptas a invalidar o depoimento prestado pelo policial durante a instrução.

Descabida a alegação da Defesa quanto à ilegalidade na busca pessoal, uma vez que os policiais responsáveis pela abordagem afirmaram ter visualizado o réu, em local conhecido pela prática de tráfico de drogas, com uma sacola no colo, de forma que está mais do que justificada as fundadas razões para a busca pessoal do réu. Não bastasse, o suspeito tentou correr com a aproximação dos policiais.

Além disso, a quantidade de droga encontrada e as demais circunstâncias da apreensão, tais como a variedade, o local da abordagem, conhecido ponto de tráfico, e a forma em que era transportada, além do dinheiro localizado com o acusado, sem comprovação lícita, trazem elementos suficientes de que ele tinha a droga para entrega a terceiros.

Dessa forma, entende-se que o delito de tráfico de drogas está fartamente comprovado.

Passo à fixação da pena.

Atendendo aos ditames do art. 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base do réu em 1/6 acima do mínimo legal em razão da vultuosa quantidade de drogas apreendidas -44 porções de cocaína (48,4g), 79 porções de crack (21,8g) e 32 porções de maconha (86,1g)-, fator que justifica a majoração da reprimenda penal, na medida em que incrementa o potencial ofensivo à saúde pública (bem jurídico tutelado pela norma penal), revelando uma maior reprovabilidade da conduta do agente (STF, HC 73.097, rel. Min. Maurício Corrêa, HC nº 76.543-5, rel. Min. Sydney Sanches; STJ, HC nº35.539, rel. Min. Paulo Medina, HC nº 35.795, rel. Min. Nilson Naves, HC nº 35.159, rel. Min. Hamilton Carvalhido)- perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Sobre o potencial lesivo da quantidade de cocaína e crack apreendida:

"A cocaína pode produzir uma intoxicação grave e por vezes inesperadamente com pequenas doses. A dose letal pode estar entre 0,8 a 1,2 g para um homem de 70 kg. No entanto, fumadores de base livre reportam uso de quantidades que excedem a 1 g. Em contrapartida, há casos em que se pode ocorrer o óbito com uma dose extremamente baixa de 20 mg. Isto pode ser explicado pela ocorrência da tolerância reversa que se caracteriza ou pelo aumento da susceptibilidade ao aparecimento de convulsões em doses consideradas recreacionais ou por uma excitação aumentada obtida em doses menores em usuários crônicos, fato que pode ser explicado pela diminuição da biossíntese dos neurotransmissores, o que leva a uma potencialização dos efeitos excitatórios." (Passagli, Marcos; Toxicologia Forense – Teoria e Prática, 5ª ed., Millennium: Campinas, 2018 – pg. 180-1).

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na última etapa, não deve incidir a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Não se desconhece que a quantidade do entorpecente, nos termos da Repercussão Geral no ARE nº 666.334/AM, rel. Min. Gilmar Mendes, deve ser ponderada em apenas uma das fases da dosimetria da pena, sob pena de bis in idem.

Todavia, diante das demais circunstâncias do delito - Além da quantidade, o réu foi preso em flagrante com três espécies diversas de entorpecentes, notadamente "crack", em local conhecido como ponto de tráfico, sabidamente dominado por facções criminosas, portanto, sem espaço para "traficantes ocasionais estranhos à organização criminosa", além de não ter comprovado de forma mínima o exercício de atividade lícita e informado aos policiais que se dedicava ao narcotráfico há algum tempo - parece-me claro o acentuado envolvimento do acusado no comércio de drogas, ou seja, a não ocasionalidade da conduta.

Repita-se que, nesta etapa, não há bis in idem na valoração da quantidade de drogas, já que tal circunstância foi utilizada apenas supletivamente, conjugada com outros vetores do caso concreto, para o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Nessa linha, posiciona-se o e Superior Tribunal de Justiça:

"Não há bis in idem quando o Tribunal a quo fixa a pena-base acima do mínimo em razão da quantidade e natureza da droga apreendida e afasta o redutor do art. 33 § 4º da Lei n. 11.343/2006 em razão da dedicação do paciente à atividade criminosa, que restou evidenciada pela quantidade e nocividade da droga apreendida (um quilo de maconha). Também não há bis in idem quando a quantidade e a natureza da droga são consideradas na primeira fase da dosimetria da pena e, logo depois, no momento da fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda" (STJ, AgRg no Resp 1690827 MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

No mesmo sentido o e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"(...) Frise-se, por oportuno, a inaplicabilidade do redutor especial inserto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tal como decido monocraticamente. Como cediço, ao editar o mencionado dispositivo legal, o legislador objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, representado por aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, conseqüentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante habitual. Em outras palavras, para a situação do mercador novato de pequena expressão, o chamado "traficante de primeira viagem", como se pode qualificar aquele que possui "estoque" diminuto para negociar durante um curto período e, em regra, suprir o próprio vício é que a lei previu a benesse como forma de abrandar seu maior rigor punitivo. Nessa quadra, a par da primariedade, os elementos angariados aos autos demonstram, à saciedade, que as circunstâncias fáticas, concretamente recolhidas no curso das investigações e comprovadas em Juízo, são inconciliáveis com a

traficância ocasional. Isso porque, o réu foi flagrado transportando e guardando exacerbada quantidade de entorpecentes (247 porções de maconha, 406 pinos de cocaína e 438 porções de crack), com naturezas extremamente destrutivas e nocivas, suficiente a atingir inúmeros usuários, de sorte a evidenciar a dedicação às atividades criminosas (narcotraficância). Nem se cogite a ocorrência do intolerável bis in idem, pois a quantidade dos entorpecentes, muito embora sopesada na primeira fase da dosimetria penal, não foi aqui considerada de forma isolada para o afastamento do benefício legal, ao contrário, as circunstâncias fáticas do flagrante policial (o que inclui natureza, quantidade e diversidade dos entorpecentes, situação de fuga à abordagem, em ponto com denúncias reiteradas da traficância), em conjunto, evidenciam dedicação habitual à atividade criminosa, sendo absolutamente implausível o reconhecimento do privilégio." (Apelação Criminal nº 1500603-96.2021.8.26.0540, Rel. Des. CLÁUDIA FONSECA FANUCCHI, j. 13 de dezembro de 2021).

Ainda sobre o redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06:

"(...) Cabe salientar que 'a conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade da droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas', para os fins a que alude o citado artigo de lei (STF, RHC nº 94.806, relatora Ministra Cármen Lúcia). Na realidade, a qualificação do agente como pessoa dedicada às atividades criminosas situação que afasta a incidência da causa de diminuição de pena estampada no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006 pode vir assentada na prova indiciária, tal como esta se acha definida no artigo 239, do Código de Processo Penal, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado (artigo 155, do Código de Processo Penal), não se exigindo prova direta desta circunstância, sob pena de inviabilização da repressão penal a este tipo de delito, dada a dificuldade de se obter uma prova deste tipo (STF, HC nº 101.519, rel. Min. Luiz Fux). Consoante salientado pelo Ministro Luiz Fux, em passagem bastante elucidativa de seu voto, 'os criminosos não circulam com uma 'carteira de identificação de pessoa dedicada a atividades criminosas'. Deveras, na interpretação do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, há que se atentar para o elemento teleológico, na dicção do artigo 5º, da Lei de Introdução ao Código Civil (FRANCISCO AMARAL, Direito Civil, Introdução, Renovar, 12 edição, pp. 88/89; JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito, Introdução e Teoria Geral, Renovar, 2ª edição, pp. 430/431), vale dizer, no sentido de que o escopo da lei foi de beneficiar com uma sensível redução da pena aquele agente que pela primeira vez se lança no mundo criminoso, cuja conduta não representa um maior perigo para a coletividade, de sorte que a pena reduzida, ainda que considerada a gravidade do tráfico de entorpecentes, afigura-se suficiente para a ressocialização e reprove suficientemente o comportamento. Essa não é, decididamente, a situação dos réus." (TJSP, Ap nº 1501840-05.2020.8.26.0540, Des. Rel. LAERTE MARRONE, j. 28.04.21).

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, I, DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. AFASTAMENTO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. ANÁLISE DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA OU DE SER INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADES NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DENEGADA. 1. A causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da lei 11.343/06 está condicionada ao preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. [...] 3. A conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza do entorpecente, os apetrechos utilizados e as circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a

dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes: RHC 94.806/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/04/2010; HC 116.541/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/6/2013; HC 98.366/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 5/2/2010. [...] (STF HC 121.057/SP Rel. Min. Luiz Fux j. 25.02.14 DJU 18.03.14).

"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA, MAUS ANTECEDENTES E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PRESUNÇÃO HOMINIS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS. APTIDÃO PARA LASTREAR DECRETO CONDENATÓRIO. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. DESCABIMENTO NA VIA ELEITA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A AFASTAR A MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06, ANTE A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ORDEM DENEGADA. 1. O §4º do artigo 33 da Lei de Entorpecentes dispõe a respeito da causa de diminuição da pena nas frações de 1/6 a 2/3 e arrola os requisitos necessários para tanto: primariedade, bons antecedentes, não dedicação à atividades criminosas e não à organização criminosa. 2. Consectariamente, ainda que se tratasse de presunção de que o paciente é dedicado à atividade criminosa, esse elemento probatório seria passível de ser utilizado mercê de, como visto, haver elementos fáticos conducentes a conclusão de que o paciente era dado à atividade delituosa. 3. O princípio processual penal do favor rei não ilide a possibilidade de utilização de presunções 'hominis' ou 'facti', pelo juiz, para decidir sobre a procedência do 'ius puniendi', máxime porque o Código de Processo Penal prevê expressamente a prova indiciária, definindo-a no art. 239 como 'a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias'. Doutrina (LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162). Precedente (HC 96062, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-02 PP-00336). 4. Deveras, o julgador pode, mediante um fato devidamente provado que não constitui elemento do tipo penal, utilizando raciocínio engendrado com supedâneo nas suas experiências empíricas, concluir pela ocorrência de circunstância relevante para a qualificação penal da conduta. 5. A criminalidade dedicada ao tráfico de drogas organiza-se em sistema altamente complexo, motivo pelo qual a exigência de prova direta da dedicação a esse tipo de atividade, além de violar o sistema do livre convencimento motivado previsto no art. 155 do CPP e no art. 93, IX, da Carta Magna, praticamente impossibilita a efetividade da repressão a essa espécie delitiva. 6. O juízo de origem procedeu a atividade intelectual irrepreensível, porquanto a apreensão de grande quantidade de droga é fato que permite concluir, mediante raciocínio dedutivo, pela dedicação do agente a atividades delitivas, sendo certo que, além disso, outras circunstâncias motivaram o afastamento da minorante. 7. In casu, o Juízo de origem ponderou a quantidade e a variedade das drogas apreendidas (1,82g de cocaína pura, 8,35g de crack e 20,18g de maconha), destacando a forma como estavam acondicionadas, o local em que o paciente foi preso em flagrante (bar de fachada que, na verdade, era ponto de tráfico de entorpecentes), e os péssimos antecedentes criminais, circunstâncias concretas obstativas da aplicação da referida minorante. 8. Ordem denegada." (STF HC 111.666/MG Rel. Min. Luiz Fux j. 08.05.12 DJU 23.05.12).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA: INADMISSIBILIDADE. DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO VOLTADA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA: CIRCUNSTÂNCIAS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06 E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA: IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. [...] 6. Os fatos que deram ensejo à não aplicação da causa de diminuição de pena prevista na Lei de Tóxicos são hígidos e suficientes para atestar a dedicação do Paciente às atividades criminosas. 7. A conduta social

do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas. [...] (STF HC 109.236/SP Rel. Min. Cármen Lúcia j. 13.12.11 DJU 14.23.12).

Estabiliza-se, assim, as sanções em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

O valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do réu.

Anote-se que o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 44 da Lei 11.343/06, nas partes em que se vedava a concessão de liberdade provisória (HC n. 104.339, rel. Min. Gilmar Mendes) e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (HC n. 97,256, rel. Min. Ayres Britto), bem como do parágrafo 1º do art. 2º da Lei n. 8072/90, que impunha o regime inicial fechado (HC n 111.849, rel. Min. Dias Toffoli).

Todavia, a gravidade in concreto do delito, considerando a quantidade e diversidade das drogas, assim como o alto potencial lesivo da cocaína e do crack para saúde pública, indica um grau acentuado de culpabilidade, de forma que o regime inicial fechado mostra-se necessário para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE COMO FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL E PARA A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ORDEM DENEGADA. Possibilidade de fixar regime inicial fechado e de afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. Precedentes.Ordem denegada." (STF - HC 119.515/AC - Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 03.12. - DJU 10.12.13)

Pelo mesmo motivo, não é hipótese de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, insuficiente para prevenção e reprovação da conduta.

Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal para CONDENAR o réu WESLEY CARVALHO OLIVEIRA, qualificado nos autos, a cumprir pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, no unitário mínimo, por incursão no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade (fls.48-9 e 128-9).

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Após o trânsito em julgado, determino a destruição da contraprova das drogas, bem como decreto o perdimento do valor apreendido, em favor do Funad, eis que comprovadamente obtidos com a narcotraficância, nos termos dos arts. 63 e 72 da Lei n.º 11.343/2006.

Em relação ao celular apreendido, nos termos dos artigos 123 do Código de Processo Penal e 516 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, ficará disponível para os interessados, desde que comprovada a propriedade, pelo prazo de 90 dias a contar da data do trânsito em julgado. Decorrido o prazo sem manifestação, fica determinado seu perdimento, para posterior alienação em leilão ou destruição, se o caso.

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella -Juiz de Direito  
(assinado eletronicamente)

Mauá, 08 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA